

1500050-71.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500050-71.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500050-71.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Gleison Diego Mascari e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra GLEISON DIEGO MASCARI, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe as condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 129, § 12, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que, no dia 1º de novembro de 2020, por volta de 15h57, na Rua Turmalina, n.º 140, no bairro Jardim Dois Mil, nesta cidade e comarca de Itápolis, o denunciado Gleison Diego Mascari vendeu 0,72 gramas de cocaína, acondicionada em um invólucro plástico, substância que causa dependência física e psíquica (vide laudo de exame químico-toxicológico de fls.11/13), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ofendeu a integridade corporal do policial militar Cleiton Braz Alves da Silva, que estava no exercício da função, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme auto de exame de corpo de delito de fls. 16/17.

O réu foi devidamente notificado, apresentando resposta escrita às fls. 97/100.

Denúncia recebida em 21 de janeiro de 2022, conforme decisão de fls. 102/108.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidas as declarações

do(a) ofendido(a), inquiridas testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado(a) o(a) acusado(a) (fls. 150/151).
Ofício da Polícia Civil informando que o Boletim de Ocorrência, o auto de exibição e apreensão e o termo de declarações da testemunha LUCIANO DE CASTRO MONTEIRO JÚNIOR foram realizados no plantão de Ibitinga/SP, sob a presidência do Delegado de Polícia Dr. LUIZ FERNANDO MACHADO FERREIRA (fls. 165/168).
Alegações finais escritas apresentadas pelo representante do Ministério Público e pelo defensor do acusado (fls. 171/182 e 183/190).
Os autos me vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 11/13), pelos exames de corpo de delito (fls. 14/15 e 16/17) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia no dia 1º de novembro de 2020, por volta de 15h57, na Rua Turmalina, nº 140, no bairro Jardim Dois Mil, nesta cidade e comarca de Itápolis, o denunciado Gleison Diego Mascari vendeu 0,72 gramas de cocaína, acondicionada em um invólucro plástico, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Constatou, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ofendeu a integridade corporal do policial militar Cleiton Braz Alves da Silva, que estava no exercício da função, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Restou apurado que, policiais militares, durante patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um aglomerado de pessoas e presenciaram o momento em que o denunciado passou um objeto pequeno para outro indivíduo, identificado como sendo Luciano, o qual colocou tal objeto em sua cintura.

Neste momento, ambos foram abordados pela polícia, a qual, durante busca, encontrou uma porção de cocaína na posse do usuário Luciano. Logo em seguida, o denunciado empurrou o policial militar Cleiton, derrubando-o ao solo, lesionando seu braço e antebraço direitos, e fugiu do local.

Indagado na ocasião, Luciano confirmou que comprara a droga do denunciado, reconhecendo-o por meio de uma fotografia a ele mostrada, naquele momento, pelos policiais militares.

Vejamos.

O acusado(a) GLEISON DIEGO MASCARI, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que “os fatos narrados pelo policiais militares não correspondem com a verdade; Que não estava no local indicado; Que não correu dos policiais; Que não derrubou o policial; Que estava em sua residência quando ouviu um tumulto na rua e saiu portão para ver o que se tratava, quando viu uma pessoa passando correndo e gritando; Que olhou para o lado de cima da rua e viu que policiais estavam vindo e pararam defronte ao portão do interrogando e disseram que queriam adentrar em sua casa, momento que não autorizou e chamou por seu genitor, que foi atender os policiais; Que ato contínuo apanhou o celular e foi para os fundos de sua residência para chamar por seu advogado; Que os policiais ouviram que seu advogado estaria vindo e resolveram ir embora; Que não vendeu droga alguma à pessoa Luciano de Castro Monteiro Junior e nem mesmo o conhece” (fl. 53).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado GLEISON DIEGO MASCARI negou a autoria delitiva. Sustentou que não estava no local dos fatos no dia do ocorrido, mas sim na casa de sua mãe, com sua filha. Avistou uma pessoa correndo e foi até a rua para ver o que estava acontecendo. Não conseguiu identificar quem era esse indivíduo correndo. Em seguida, o interrogado voltou para casa. Ato contínuo, dois policiais quiseram entrar em seu imóvel, porém o pai do interrogado não autorizou o ingresso deles. Um desses policiais era a testemunha CLEITON BRAZ ALVES SILVA. O policial DANIEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA GODOY não esteve em sua casa. Não notou nenhum ferimento no braço do policial CLEITON. O interrogado encontra-se preso em razão de outro processo criminal, no qual o policial DANIEL também figura como testemunha.

A testemunha LUCIANO DE CASTRO MONTEIRO JÚNIOR, ao ser ouvida na fase policial, relatou que “é usuário de cocaína e que por mais de três vezes comprou drogas do indivíduo de que tratam os presentes autos no dia de hoje, salientando que não sabe nome, apelido ou outro dado que o identifique. Que estava comprando cocaína, na rua Turmalina, perto do numeral, 114, quando chegou ali uma viatura da Polícia Militar e que ao ver escondeu a porção de cocaína sob suas vestes e que todos foram “enquadrados”, e que em dado momento o vendedor, desconhecido conseguiu sair correndo e escapar dos policiais. Que pagou a importância de dez reais pela droga. Que o Policial Militar mostrou em seu telefone celular a foto do indivíduo

apelidado de Sardinha, sendo que o declarante de pronto o reconheceu como sendo o indivíduo que lhe vendeu a porção de cocaína ora apreendida e que veio somente hoje saber que o apelido dele é Sardinha e que ele se chama Cleidson. Que informa que já comprou drogas deles, perto da escola "Chico Arruda". Que ficou sabendo que Sardinha ao fugir empurrou um policial militar, o qual veio ferir o braço no muro da residência, ali do local" (sic) (fl. 08 - grifo meu).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha LUCIANO DE CASTRO MONTEIRO JÚNIOR apresentou versão inteiramente distinta para os fatos descritos na denúncia. Sustentou que a droga apreendida pelos policiais lhe foi fornecida por amigos em um churrasco. Após deixar o referido churrasco, o depoente foi até o bar da Rua Turmalina pegar uma cerveja, ocasião em que foi abordado pela polícia. Havia muitas pessoas no local da abordagem e o depoente não as conhecia. O policial que o abordou disse que o depoente deveria colaborar para ser enquadrado como usuário, e não como traficante. Segundo o policial, o depoente deveria confirmar a versão de que teria adquirido a droga de uma pessoa que estava naquele local. Apenas o depoente foi conduzido ao plantão policial em Ibitinga/SP. No interior da viatura lhe foi exibida uma fotografia, que estava no celular do policial, porém o depoente nega ter adquirido a droga do indivíduo representado na foto. O depoente não foi algemado na oportunidade. O depoente assinou o depoimento que prestou na Delpol, porém não confirma o teor do referido depoimento.

A testemunha CLEITON BRAZALVES DA SILVA, ao ser ouvida na fase policial, narrou que "Que no dia dos fatos, desempenhava suas atividades laborais, juntamente com o colega de farda CBPM Daniel, e quando estavam efetuando patrulhamento na rua Turmalina, no Jd. 2000, avistaram um aglomerado de pessoas, salvo engano 05 pessoas, sendo que dois deles estavam realizando uma transação característica da compra e venda de entorpecentes; Que tais pessoas não perceberam a aproximação do depoente e seu companheiro e, neste momento viram quando a pessoa conhecida dos meios policiais pela alcunha de "SARDINHA" passou um objeto para o outro indivíduo, depois identificado como Luciano de Castro Monteiro Junior, que o colocou em sua cintura; Que procederam a abordagem de todos, sendo também solicitado reforço para outra guarnição de policiais; Que separaram o indivíduo Luciano, que havia acabado de adquirir o objeto e iniciaram a revista pessoal; Que localizaram 01 porção a substância entorpecente com Luciano; Que com a chegada do reforço policial, o indivíduo de alcunha "SARDINHA" derrubou o depoente, vindo a causar-lhe ferimentos em seu braço e ante braço direito, e evadiu-se do local correndo a pé, sendo perseguido pelo depoente e seu colega de serviço Alex; Que "Sardinha" a saber: Gleison Diego Mascari entrou em sua residência na Rua Esmeralda, 521, Jd. Dois Mil; Que na residência de "SARDINHA", o genitor dele foi ao encontro do depoente e de seu colega para atrasá-los e disse que não autorizaria a entrada dos mesmos em sua residência, momento em que avistaram "SARDINHA" pulando o muro dos fundos e tomar rumo ignorado; Que ante a não autorização do genitor de Gleison, não foi procedido a busca em sua residência; Que Gleison "SARDINHA" é conhecido dos meios policiais, pela prática reiterada do crime de tráfico; Que em razão da queda provocada por Gleison o depoente acabou por sofrer lesões em seu braço, conforme apontou laudo médico; Que seu colega de serviço CbPm Daniel apresentou a Luciano, uma foto de GLEISON DIEGO MASCARI, vulgo "SARDINHA", tendo Luciano confirmado se tratar da pessoa que lhe vendeu a substância entorpecente, cocaína, pelo valor de R\$10,00.

Que neste ato autorizo a administração da Santa Casa a fornecer minha ficha clínica, relativa ao atendimento por mim recebido com relação aos fatos. QUE NESTE ATO MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA A PESSOA DE GLEISON DIEGO MASCARI PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL" (sic) (fl. 51 - grifo meu).

Em juízo, a testemunha CLEITON BRAZ ALVES DA SILVA sustentou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim 2000, quando avistaram o réu GLEISON DIEGO MASCARI, vulgo SARDINHA, conversando com outro indivíduo, identificado como sendo LUCIANO DE CASTRO MONTEIRO JÚNIOR. O acusado é conhecido como traficante nos meios policiais. Viram LUCIANO entregando R\$ 10,00 para o réu, que entregou uma porção de cocaína para LUCIANO. LUCIANO escondeu a porção da droga em sua cintura. O policial militar DANIEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA GODOY chamou LUCIANO para conversar na Rua Safira, enquanto o depoente ficou aguardando a

chegada de outra viatura. Ao realizar a abordagem do acusado, este resistiu e empurrou o declarante contra um muro, lesionando seu antebraço direito. Em seguida, o depoente e o policial ALEX correu atrás do acusado, que entrou na casa do pai dele, na Rua Esmeralda. O pai do réu não autorizou a entrada dos policiais na residência. Do lado de fora, puderam ver o acusado pulando muros de outras residências. O réu não foi encontrado. Foram até o plantão de Ibitinga/SP, onde LUCIANO, ao ser indagado, confessou que era usuário e que havia comprado drogas do acusado. LUCIANO não foi ameaçado, tendo confessado espontaneamente que era usuário e que havia comprado drogas do réu, embora não soubesse o nome dele. LUCIANO foi ouvido pelo escrivão de polícia, pois o Delegado não estava presente no plantão policial.

A testemunha DANIEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA GODOY, policial militar, em solo policial, disseram que “no dia dos fatos, desempenhava suas atividades laborais, juntamente com o colega de farda Sd. PM Braz, e quando estavam efetuando patrulhamento na rua Turmalina, próximo ao numeral 140, no Jd. 2000, avistaram um aglomerado de pessoas, sendo que dois deles estavam realizando uma transação característica da compra e venda de entorpecentes; Que tais pessoas não perceberam a aproximação do depoente e seu companheiro e, neste momento viram quando a pessoa conhecida dos meios policiais pela alcunha de "SARDINHA", a saber: Gleison Diego Mascari, passou um objeto pequeno para o outro indivíduo, que depois foi identificado como sendo Luciano de Castro Monteiro Junior, sendo que Luciano colocou tal objeto em sua cintura; Que procederam a abordagem de todos, sendo também solicitado reforço para outra guarnição de policiais; Que separaram o indivíduo Luciano, que havia acabado de adquirir o objeto e, efetuaram busca pessoal, tendo o depoente localizado 01 porção a substância entorpecente em sua cintura; Que com a chegada do reforço policial, o indivíduo de alcunha "SARDINHA" derrubou o policial Braz e evadiu-se do local correndo a pé, sendo perseguido pelo próprio Braz e pelo policial Alex, que havia chegado para o apoio; Que “Sardinha” logrou êxito em evadir-se de seus colegas de serviço e não foi localizado; Que tomou conhecimento de que o genitor de Gleison não autorizou seus colegas policiais a perseguirem Gleison pelo interior da residência, tendo Gleison galgado o muro dos fundos e desaparecido; Que ante a não autorização do genitor de Gleison, também não foi procedido a busca em sua residência; Que Gleison "SARDINHA" é conhecido dos meios policiais, pela prática reiterada do crime de tráfico; Que em razão da queda provocada por Gleison no policial Braz, este acabou por sofrer lesões em seu braço, conforme apontou laudo médico; Que o depoente exibiu ao autor Luciano, uma foto de Gleison Diego Mascari, vulgo "SARDINHA", tendo Luciano confirmado se tratar da pessoa que lhe vendeu a substância a cocaína, que com ele foi apreendida, pelo valor de R\$10,00 e, que aquela não era a primeira vez que adquiria entorpecente dele naquele local” (sic) (fl. 50 – grifo meu).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha DANIEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA GODOY sustentou que na data dos fatos, na altura da Rua Safira com a Rua Turmalina, avistaram dois indivíduos na esquina interagindo. Reconheceram um deles como sendo o acusado GLEISON, vulgo SARDINHA, conhecido nos meios policiais como traficante. O outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo LUCIANO, entregou uma nota de R\$ 10,00 ao réu, que lhe entregou uma porção de cocaína. LUCIANO colocou a porção de cocaína na cintura, debaixo de sua bermuda. Os dois não perceberam a presença da viatura policial. O depoente abordou LUCIANO e o soldado BRAZ ficou com o réu e outras pessoas na Rua Turmalina. Solicitaram apoio de outra viatura para que as outras pessoas fossem abordadas. Indagado, Luciano lhe disse que havia acabado de adquirir a porção de cocaína que estava em sua cintura, por R\$ 10,00, porém ele não soube dizer o nome do vendedor. Quando seus parceiros policiais foram fazer a abordagem do réu, este empurrou o soldado BRAZ contra a parede para se evadir. BRAZ acabou lesionando o braço. O réu empreendeu fuga até a Rua Esmeralda e entrou na casa do pai dele. Os policiais foram recebidos pelo genitor do acusado, que não autorizou a entrada na residência. Os policiais viram que o réu pulando os muros das casas vizinhas. Não lograram êxito em localizar o réu. Conduziram apenas o usuário para o plantão policial, oportunidade em que LUCIANO ratificou a versão que havia apresentado antes. No

plantão policial, LUCIANO reconheceu a fotografia e disse que comprou a droga do réu. LUCIANO também disse que havia comprado drogas do acusado naquele mesmo local em outras oportunidades. Flagraram a compra e venda dos entorpecentes. Nega a versão apresentada nesta audiência de instrução e julgamento pela testemunha LUCIANO. LUCIANO não foi ouvido pelo Delegado de Polícia, mas sim pelo escrivão plantonista. Não se recorda se estava ao lado de LUCIANO quando ele prestou o depoimento. O depoente não ameaçou LUCIANO em nenhum momento, seja durante a abordagem seja durante o depoimento dele na Delpol. Foi exibido para LUCIANO o álbum de fotos que fica no celular do depoente. A exibição foi feita na Delpol. Trata-se de um banco de dados fotográfico vinculado às polícias militar e civil e que só pode ser acessado pelos agentes de segurança pública, mediante senha. O depoente não viu o réu agredindo o policial BRAZ, pois nesse momento estava na Rua Safira com LUCIANO.

Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que o(a) ofendido(a) e a(s) testemunha(s) de acusação tivesse(m) qualquer motivo para pretender(em) incriminar o acusado, imputando-lhe falsamente um delito de que o sabe(m) inocente.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(a) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. A defesa pleiteou na resposta à acusação a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta é materialmente atípica.

O pleito defensivo deve ser indeferido.

O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da tipicidade, mediante uma interpretação restritiva do tipo penal.

Seu reconhecimento depende do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. São requisitos objetivos: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social do agente; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica.

Os requisitos subjetivos (dizem respeito às condições do agente e da vítima), por seu turno, são dois: (i) importância do objeto material para a vítima (devendo ser avaliado o valor sentimental do res furtiva, bem como a situação econômica do agente e do ofendido); e b) circunstâncias e resultado do crime.

No caso dos autos, verifico que nenhum dos requisitos acima encontra-se preenchido. Com efeito, a prática de quaisquer das elementares tipificadas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ainda que de ínfima quantidade de entorpecente, não pode ser considerada insignificante, porquanto cuida-se de crime de perigo abstrato, que tem como bem jurídico a ser tutelado a saúde pública, razão pela qual é irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.

Como bem destaca Guilherme Nucci, “o bem jurídico tutelado é a saúde pública e o traficante raramente se contenta em materializar o crime uma só vez. Sem a punição devida, uma vez detectada a infração penal, a reiteração é quase certa, além do que as quantidades de entorpecentes tendem a crescer cada vez mais. Por outro lado, é possível que o agente tenha sido surpreendido com pouca quantia por mera eventualidade. Em suma, constituindo crime de perigo abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro:

Forense, 2017, p. 374 – grifo meu).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HC 195985/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª Turma, j. 09/06/2015.

Desse modo, rejeito o pleito defensivo de aplicação do princípio da

insignificância.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é reincidente e possui maus antecedentes: processos n.º 0000856-64.2013.8.26.0274 e 0001685-74.2015.8.26.0274.

Ademais, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por milicianos em ponto de venda de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-

63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0000856-64.2013.8.26.0274.

Crime do artigo 33 da Lei de Drogas

Considerando-se que o acusado ostenta uma condenação definitiva que não configura reincidência, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Crime do artigo 129, § 12, do CP

Considerando-se que o acusado ostenta uma condenação definitiva que não configura reincidência, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique

a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; Resp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no Resp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; Resp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Crime do artigo 33 da Lei de Drogas

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0001685-74.2015.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Crime do artigo 129, § 12, do CP

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0001685-74.2015.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 4 meses e 2 dias de detenção.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Crime do artigo 33 da Lei de Drogas

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Crime do artigo 129, § 12, do CP

Reconheço a majorante prevista no § 12, do artigo 129, do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3. Fixo a pena definitiva em 5 meses e 12 dias de detenção.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. Do concurso de crimes

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime de tráfico de drogas (6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa) e o crime de lesão corporal (5 meses e 12 dias de detenção), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa e 5 meses e 12 dias de detenção. Deverá ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP.

6. Regime de cumprimento de pena.

Crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

Crime do artigo 129, § 12, do CP

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime aberto, os maus antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

7. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como os maus antecedentes e a reincidência do agente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

8. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o acusado GLEISON DIEGO MASCARI nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e do artigo 129, § 12, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, às penas privativas de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e 5 meses e 12 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Deverá ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP.

2. Embora o(a) acusado(a) esteja respondendo ao processo preso, verifico que a prisão foi decretada em outro processo criminal. Desse modo, no presente feito, não se aplicam as disposições do artigo 316, § único, e 387, § 1º, ambos do CPP.

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.

Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA